

1500539-47.2019.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 01)

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500539-47.2019.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500539-47.2019.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2170452/2019 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 3355124 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 2170452 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 2170452 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 2170452 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 2170452 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 2170452 - 01º D.P. CAPÃO BONITO, 829/19/414 - 01º D.P. CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL PONTES DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de CARLOS DANIEL PONTES DE JESUS, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos (I) no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06; e (II) no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia (fls. 196-199), no dia 1º de maio de 2019, por volta das 22:15 horas, na Rua Emílio Fernandes Sanches, cruzamento com a Rua José Baitaca, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, CARLOS, em concurso e com envolvimento do então adolescente JONATHAN HENRIQUE DA COSTA, nascido em 25/06/2003, com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, um aderindo à vontade do outro, de forma livre e consciente, mantinham sob sua guarda drogas, 5 porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", com massa bruta total de 1,58 grama e líquida de 0,75 grama; e 12 porções de cocaína em forma de "crack", acondicionadas em plástico translúcido fechado por meio de nó, com massa bruta total de 2,37 gramas e líquida de 1,26, substâncias capazes de causar dependência, previstas na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 01).

Consta, também, que, em data incerta, mas antes de 1º de maio de 2019, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, CARLOS possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre 12, sem maiores descrições, com imagem às fls. 101, 156/157 e 184, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (FATO 02).

De acordo com o Ministério Público, por ocasião do "FATO 01", uma guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento de rotina recebeu informações de um morador da Vila Aparecida de que dois indivíduos estavam vendendo entorpecentes pelo local dos fatos. Chegando lá, a guarnição avistou CARLOS abaixado, mexendo em uma pilha de entulhos que estava na calçada. Ao notar os policiais, ele se afastou em direção ao adolescente JONATHAN, que estava próximo dali. Ambos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles, apenas R\$ 85,20 em cédulas de valores variados e em moedas, típico do "tráfico de rua", em poder de CARLOS.

Vistoriado o referido entulho, os policiais encontraram as porções de entorpecentes acima descritas (cocaína e "crack"), prontas para a venda, e uma mochila contendo diversos microtubos "Eppendorf" vazios, habitualmente utilizados para acondicionar cocaína.

Na ocasião, os telefones celulares do réu e do adolescente também foram apreendidos e, posteriormente, periciados, conforme laudo e relatório acostados aos autos, revelando imagens de "pinos" de cocaína, cigarros artesanais de "maconha", uma porção grande de "maconha" e de armas de fogo.

O local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, as informações pretéritas da atuação de dois indivíduos como vendedores (o que foi confirmado pela ação policial), a forma de acondicionamento das drogas, sua diversidade e tudo mais quanto consta dos autos demonstram, para o Ministério Público, que a finalidade era, de fato, o tráfico de entorpecentes, inclusive com envolvimento do adolescente JONATHAN.

Por fim, cumpre narrar que, por ocasião do "FATO 02", CARLOS manteve sob sua guarda e posse, nas dependências de sua residência, a arma de fogo acima descrita, tratando-se de uma espingarda calibre 12. Indagado a respeito quando preso pelo "FATO 01", ele alegou que já havia vendido o objeto a terceiro não identificado, deixando, por óbvio, de apresentar qualquer autorização ou licença para posse ou porta da arma de fogo.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 200-202, seguindo-se a regular citação do réu (fl. 217), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 220-226).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da

denúncia com a condenação do réu pelo delito de tráfico nos termos da denúncia, e absolvição em relação à posse de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A Defesa requer a absolvição por ausência de provas ou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal com os consectários daí decorrentes. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 01)

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04-07), auto de exibição e apreensão (fls. 08-10), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80-83) positivo para cocaína, laudo de perícia em telefone celular (fls. 98-104), local dos fatos (fls. 109-110) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu, na fase policial, disse que: no dia dos fatos, estava conversando na rua com seu colega JONATHAN próximo da casa dele e foram abordados por policiais militares; com o declarante nada foi encontrado de ilícito e pelo que viu também nada de errado encontraram com JONATHAN; não viu onde os policiais encontraram a droga que apresentaram no plantão policial na delegacia; conhece JONATHAN há bastante tempo pois moram próximos; não é usuário de drogas; tem passagem por tráfico de drogas no ano passado e está assinando no fórum; quanto a seu colega JONATHAN nunca soube se ele vende ou usa drogas (fls. 66).

Em aditamento, disse que: atualmente trabalha registrado como colhedor de laranja; acerca das fotos encontradas no celular relata que a espingarda maior era uma calibre 12 de sua propriedade, que vendera para um homem de Guapiara em troca de uma bicicleta há aproximadamente 3 anos; não se recorda quem é tal pessoa; as outras armas são de airsoft e já vendeu todas para pessoas desconhecidas; não está mais no "corre"; vendeu tudo pois agora está direito e está trabalhando e mantendo a sua família (fls. 180).

Interrogado em juízo disse que: estavam na rua, em pé na esquina; não estava agachado; não estava traficando; guardou a bolsa de pinos no entulho; é réu confesso; a arma tinha pego para fazer rolo e era velha, bem chegou a utilizar; tinha foto no celular da arma.

A testemunha, Jonathan Henrique da Costa, ouvido em solo policial, disse que: no dia dos fatos, estava conversando na rua com seu colega CARLOS próximo de sua residência quando foram abordados por policiais militares; com o declarante nada foi encontrado e pelo que viu também nada de ilícito encontraram com CARLOS; não viu onde os policiais encontraram a droga; somente viu a droga aqui na Delegacia; conhece CARLOS há bastante tempo pois moram próximos; o declarante não é usuário de drogas e nem mesmo vende entorpecentes; quanto a seu colega CARLOS nunca soube se ele vende ou usa drogas. (fl. 65).

Em juízo relatou que: estavam conversando; os policiais chegaram e os abordaram; os policiais encontraram drogas e os levaram para a Delegacia; não sabe onde os policiais acharam a droga.

A testemunha, Tiago Domingues Rocha, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: no dia dos fatos, juntamente com seus colegas de guarnição, realizava patrulhamento pela Vila Aparecida; foram informados por um morador do bairro que dois indivíduos estavam vendendo drogas na rua; indicado o local do fato, a equipe se deslocou e visualizaram uma pessoa que estava abaixado mexendo em um monte de entulho; este ao ver a viatura saiu do local e foi até onde estava JONATHAN; imediatamente, ambos foram abordados; na revista pessoal nada de ilícito foi

encontrado em poder do investigado e do adolescente, somente o valor de R\$ 85,20; os agentes retornaram até o local onde CARLOS, agora identificado, estava abaixado e lá foi encontrado um tubinho plástico contendo 12 pedras de substâncias semelhantes à crack e mais cinco eppendorfs contendo um pó branco semelhantes à cocaína; também foi encontrado uma mochila na cor vermelha contendo diversos eppendorfs vazios; CARLOS e o adolescente negaram que os entorpecentes eram de suas propriedades. (fl. 67).

Em juízo relatou que: a equipe estava em patrulhamento pela Vila Aparecida quando um morador afirmou que nas proximidades havia dois indivíduos vendendo drogas; foram até o local indicado e primeiro avistaram Jhonatan. CARLOS estava abaixado mexendo no entulho; abordaram ambos e encontraram apenas dinheiro; foram até o entulho e localizaram 12 pedras de crack e 5 pinos de cocaína e mais uma mochila vermelha; ambos negaram a propriedade das drogas.

A testemunha, Rafael Fagundes Araújo Rocha, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: no dia dos fatos, juntamente com seus colegas de guarnição em patrulhamento pela Vila Aparecida, nesta cidade, foram informados por um morador do bairro que dois indivíduos estavam vendendo drogas; tal morador indicou o local do fato; a equipe se deslocou; se depararam com uma pessoa posteriormente identificada como CARLOS, que estava abaixado mexendo em um monte de entulho; este ao visualizar a viatura saiu do local e foi até onde estava JONATHAN, este menor de idade; ambos foram abordados, sendo que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder do investigado e do adolescente, somente o valor de R\$ 85,20 com CARLOS; os agentes retornaram até o local onde CARLOS estava abaixado e lá foi encontrado um tubinho plástico contendo 12 pedras de substâncias semelhantes à crack e mais cinco eppendorfs contendo um pó branco semelhantes à cocaína; também foi encontrada uma mochila na cor vermelha contendo diversos eppendorfs vazios; CARLOS e o adolescente negaram que os entorpecentes eram de suas propriedades; as partes e os objetos apreendidos além dos entorpecentes foram apresentadas no plantão onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos. (fl. 85).

Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento e receberam informações de populares dizendo que dois indivíduos estavam realizando a venda de drogas; viram CARLOS mexendo em entulho; quando a viatura chegou ele se aproximou do adolescente; com CARLOS encontraram dinheiro; no entulho encontraram as drogas e os encaminharam para a Delegacia.

A testemunha, José Luiz Vieira, policial civil, ouvido em juízo, disse que: a ocorrência chegou pela polícia militar com a abordagem de CARLOS e do adolescente; foram abordados nas imediações do local dos fatos; não conseguiu levantar maiores informações sobre os réus; na região há tráfico de entorpecentes mas impera a "lei do silêncio"; há diversas biqueiras na região.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta

Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que réu prestou um depoimento um tanto confuso em juízo. Ao mesmo tempo em que se disse "réu confesso" procurou se esquivar da acusação de estar comercializando os entorpecentes.

De todo modo, ambas as testemunhas ouvidas em juízo mantiveram a versão apresentada na Delegacia dando conta de terem recebido a indicação de um popular enquanto estava realizando patrulhamento próximo ao local dos fatos. Esse popular relatou que havia duas pessoas realizando o tráfico nas proximidades e, quando os policiais se dirigiram até o local, encontraram CARLOS mexendo no entulho.

Posteriormente, no local em que CARLOS estavam mexendo, os policiais encontraram as drogas apreendidas e, com o réu, dinheiro em diversas notas e moedas, característica do tráfico de rua.

Não havendo nos autos qualquer evidência para desacreditar a palavra das testemunhas, tem-se por comprovada a autoria e materialidade do delito.

Quanto à participação do adolescente, tudo que se verifica é o relato do transeunte que notificou a ocorrência do tráfico à polícia. Com ele nada foi encontrado e o depoimento dos policiais não acrescentam qualquer elemento que permita concluir que ambos estivessem de fato atuando em conjunto.

Não está configurada, assim, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

2.2 Sobre o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (FATO 2)

O Ministério Público requereu a absolvição do réu em relação ao delito do FATO 02. Com efeito, a denúncia sustentou-se basicamente nas imagens captadas no celular do réu. Em juízo ele admitiu que de fato possuiu a referida espingarda, contudo menciona que a vendeu muito tempo antes da sua abordagem.

Diante desse quadro, não é possível precisar até quando efetivamente o réu deteve a posse da arma e tampouco se era apta para a realização de disparos.

Nessas circunstâncias, a absolvição por ausência de provas se impõe.

2.3 Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade

O réu, de forma consciente e espontânea, mantinha sob sua guarda drogas, 5 porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", com massa bruta total de 1,58 grama e líquida de 0,75 grama; e 12 porções de cocaína em forma de "crack", acondicionadas em plástico translúcido fechado por meio de nó, com massa bruta total de 2,37 gramas e líquida de 1,26, substâncias capazes de causar dependência, previstas na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A conduta se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa

nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu CARLOS DANIEL PONTES DE JESUS nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

2.4 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.4.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida cocaína e crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 5 porções de cocaína acondicionadas em microtubos plásticos do tipo “Eppendorf”, com massa bruta total de 1,58 grama e líquida de 0,75 grama; e 12 porções de cocaína em forma de “crack”, acondicionadas em plástico translúcido fechado por meio de nó, com massa bruta total de 2,37 gramas e líquida de 1,26. Não há no caso, desborde do tipo penal em razão dessa quantidade.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceu-se uma circunstância como negativas (a natureza da substância), acresço ao piso 1/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se que há circunstância atenuante aplicável à hipótese, pois o agente era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, tornando a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e ao fato de não integrar organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em

2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

2.4.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 2 anos e 6 meses de detenção), o fato de o réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2.4.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos, satisfazendo o requisito objetivo. Além disso, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe foram desfavoráveis. Sua conduta não se mostra incompatível com a vida em sociedade, já que o crime não afrontou a integridade física de outrem, pelo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP), em entidade a ser estabelecida pelo juízo da execução, pelo prazo da condenação e prestação de serviço e a prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.4.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.4.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Recepção. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência

prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal – Vedação da reforma tio in pejus – Penas inalteradas – Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada – Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Detração da pena – questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal – Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu CARLOS DANIEL PONTES DE JESUS pela prática do delito previsto no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 (FATO 01) às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 116 dias-multa.

b) ABSOLVER o réu CARLOS DANIEL PONTES DE JESUS da acusação de prática do delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva, pois o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto e a custódia cautelar seria mais rigorosa do que o próprio cumprimento da reprimenda.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 30 por ser produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA